

Por meio da presente, requer-se: (i) a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora;
(ii) o ingresso do Município no polo passivo da demanda, na forma da parte final do inciso II do
art. 7º da Lei 12.016/2009



AO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE GUARAPARI/ES.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002479-81.2021.8.08.0021

GABRIEL COSTA ARAÚJO, brasileira, casado, servidor público atualmente exercendo o Cargo de Secretária Municipal da Fazenda, Carteira de Identidade nº 569.967 SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 710.380.197-53, domiciliado à Rua Alencar Moraes de Rezende, nº100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, nos termos do Artigo 7º, inciso I da Lei 12.016/2009

PRESTAR INFORMAÇÕES

ao Mandado de Segurança impetrado pela empresa ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA, dizendo e requerendo o que segue:

I- BREVE SÍNTESE

O impetrante em síntese informa em sua peça inaugural que integralizou na constituição de seu capital societário, o Apartamento 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na Av. Viña del Mar, na Enseada Azul - Nova Guarapari, situado no Município de Guarapari/ES.

Este apartamento foi adquirido pelo então proprietário, casado em comunhão universal de bens, Fernando de Abreu Júdice e Ana Rita Marques Júdice, e constava na Declaração de Imposto de Renda no valor de **R\$ 220.000,00 (duzentos vinte mil reais)**.

Esclarece ainda o impetrante que o referido valor não comportou atualização no momento da integralização por opção do contribuinte, a fim de não ficar sujeito ao imposto de renda sobre o ganho de capital, e que uma vez integralizado o imóvel, nos termos do quanto permitido pelo art.23 da Lei nº9.249/1995, impera a imunidade do ITBI prevista no texto constitucional;

Alega o impetrante, que a autoridade coatora reconhece somente, em parte, a imunidade mencionada, apenas até o valor de integralização do imóvel, ao passo que entendeu



pela incidência do imposto sobre o valor da diferença a ser apurada, exigindo o recolhimento do tributo no montante de R\$ 17.690,11 (dezessete mil seiscentos e noventa reais e onze centavos), defendendo que tal circunstância caracteriza-se como abusivo e ilegal; que se baseou em interpretação equivocada da Procuradoria Geral do Município sobre o Tema 796 apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 796.376/SC, pautado sobre o regime de repercussão geral.

Afirma por fim a impetrante, que faz jus a imunidade (não incidência) total do ITBI quanto à integralização do respectivo imóvel pelo valor constante da declaração de bens e direitos do seu sócio, como parte do capital na constituição da pessoa jurídica, na forma do que dispõe o artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição da República e pugna pela concessão da medida liminar para efeito de ordenar à autoridade impetrada e aos demais prepostos da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Guarapari que se abstenham de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezessete mil seiscentos e noventa reais e onze centavos), apurada em 28/05/2021, ou qualquer outra sobre a diferença entre o valor do imóvel destacado.

II – DAS INFORMAÇÕES

Em 25 de setembro de 2020, através do processo de nº18384/2020 a empresa ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 34.727.838/0001-01, através de seu sócio FERNANDO DE ABREU JÚDICE, CPF nº036.069.537-04, requereu junto ao Município de Guarapari, o reconhecimento da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA prevista no artigo 156, §2º, II da Constituição Federal, e/ou a NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI com base na Lei Complementar nº08/2007, Art.224, inciso I, do seguinte imóvel dado à integralização de capital social da requerente:

- a) 01 (um) apartamento residencial de nº 201, com 02 (duas) vagas de garagem, Edifício Praia de Bacutia, situado na Avenida Viña Del Mar, nº298, Guarapari/ES, CEP: 29.206-170, adquirido (a) na data de 29/06/2006, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada no livro 139S2, as folhas 207/209 do Cartório Sarlo, imóvel registrado no Cartório de Registro de Guarapari/Es 2º Ofício, sob matrícula nº 43.799, livro 2, valor R\$ 220.000,00 (duzentos vinte mil reais)

Ato contínuo, o processo foi encaminhado a Subgerência de Tributos e conforme previsto no Artigo 206 da Lei Complementar de nº 008/2007(Código Tributário Municipal), foi designado o Fiscal de Rendas Wallace Jose Motta, para avaliação do supracitado imóvel.

Realizada a avaliação do imóvel em 05/10/2020, apurou-se um valor atual de R\$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), dessa maneira, considerando o valor de integralização do imóvel no valor pelo qual o mesmo foi adquirido e 2006, qual seja, R\$220.000,00(duzentos e vinte mil reais), o processo administrativo nº18384/2020, foi encaminhado a Procuradoria Geral do Município para análise e parecer em face da decisão do STF sobre o aludido assunto.



Em parecer jurídico nº 005/2020/PGM/ADC, exarado pelo Procurador Municipal Arthur Daher Colodetti foi tecida o seguinte entendimento:

(...)

11. Ao lado do que acima foi dito, importa destacar que a imunidade em exame adstringe-se ao valor necessário à integralização do capital social, pois o artigo 36 do Código Tributário Nacional faz menção de que a não-incidência (rectius, imunidade) limita-se ao capital subscrito (in casu, incorporado), não sendo razoável sua concessão quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente.

12. Diante desse cenário, à luz do estatuído no art.36 do CTN, caso o valor de mercado do imóvel que, por força da incorporação, passará ao patrimônio da Requerente supere o valor a ele atribuído para fins de integralização, o ITBI incidirá sobre a parte excedente.

13. Quanto ao ponto, forçoso destacar a tese fixada pelo Excelso Pretório no tema 796, interis: "A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".⁸

⁸ AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ITBI. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DE IMUNIDADE EM RELAÇÃO A TODO O VALOR DOS BENS. INVIABILIDADE. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DO SÓCIO. BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO, EM PARTE PROVIDO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR, PARA FINS DE SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART.151, I, DO CTN). "A imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso I do §2º do art 156, da Constituição Federal de 1988 impede a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis 'inter vivos' somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Vale dizer, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá incidência do tributo". (TJSC - Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2011.073712-5, de São João Batista, rel. Des. Jaime Ramos, j.15.5.2012)" (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n.014.003946-8, de São João Batista, rel. Des. João Henrique Blasi, j.27-05-2014). (TJSC, Agravo de Instrumento n.2015.035061-9, de Blumenau, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j.03-11-2015). "

14. No caso vertente, pois, impõe-se a esta Secretaria:

(a) verificar se o valor de mercado do bem a ser integralizado no capital da Requerente supera o valor das cotas que por meio dele serão subscritas;

(a.1) em caso afirmativo, lançar o ITBI sobre a parcela excedente;

(b) se o valor de mercado do bem não superar o valor das cotas que por ele serão subscritas ou, em superando, efetuado o pagamento do tributo sobre a parcela excedente, autorizar a integralização do imóvel em tela ao capital da Requerente independentemente do prévio recolhimento do ITBI, sem prejuízo de sua cobrança no momento oportuno, na forma da alínea "c" abaixo;

(c) com vistas a aferir se a requerente faz jus à imunidade invocada, no que concerne a parcela não excente, encerrado o triênio de que trata o §2º do art.37 do CTN, analisar a contabilidade da Requerente, perscrutando qual sua atividade preponderante, isto é, qual a origem da maioria de suas receitas operacionais,



considerando não só as receitas próprias (da Requerente), senão também havidas pelas sociedades das quais seja sócia.

(c.1) identificada a preponderância da atividade imobiliária nas receitas operacionais da Requerente, **lançar** o ITBI sobre a parcela não excedente, devidamente atualizada.

Dessa maneira, mediante parecer jurídico, foi lançado o ITBI sobre o valor excedente no montante de R\$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), o que gerou a guia de ITBI para recolhimento no valor de R\$ 17.690,11 (dezessete mil seiscentos e noventa reais e onze centavos).

Insta registrar, que o contribuinte à época, mediante apresentação de documentos comprobatórios, poderia ter impugnado o valor avaliado do imóvel (R\$1.100.000,00), o que não foi realizado.

Aqui, é importante avocar o princípio constitucional da legalidade, descrito no Art. 5º, II da Constituição Federal, visto que este representa a subordinação da Administração Pública à vontade popular, isto é, o exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, a Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei.

Dessa forma, é de bom alvitre ressaltar, que o ora subscritor, ao exercer função de agente político como Secretário Municipal da Fazenda, encontra-se adstrito ao cumprimento da lei, em atendimento ao princípio constitucional da legalidade e abdicar ou se omitir, por conta própria e risco, a cobrança da guia de ITBI acima citada, ocasionaria em renúncia de receita e consequente lesão ao erário, conforme Art.10 da *Lei Federal nº 8.429/92*

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda...

Ademais, sobre o assunto da presente lide, o Município de Guarapari, para fins de cobrança do ITBI sobre o valor excedente no montante de R\$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) se respaldou na manifestação do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 796.376/SC, sobre o regime de Repercussão Geral, conforme descrito abaixo:

PLENÁRIO EXTRATO DE ATA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.376 PROCED. : SANTA CATARINA RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES RECTE.(S) : LUSFRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA ADV.(A/S) : TIAGO MENDONÇA (31119/SC) E OUTRO(A/S) RECD.(A/S) : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA ADV.(A/S) : CARLOS SIMAS ROCHA (18895B/SC) INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF ADV.(A/S) : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA (81438/RJ) Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 796 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o



valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Falaram: pela recorrente, a Dra. Graziela Biason Guimarães; e, pela interessada, o Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020. Composição: Ministros Dias Toffoli (Presidente), Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Carmen Lilian Oliveira de Souza Assessora-Chefe do Plenário

Nota-se que no Acórdão supracitado é afirmado que o **Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 796 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes**, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Para tanto, citamos abaixo *ipsis litteris* o voto do Ministro Alexandre de Moraes no presente Recurso Extraordinário, a fim de que não reste dúvidas que o entendimento do Município é condizente com o tema 796, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.376 SANTA CATARINA
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE. (S): LUSFRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADV. (A/S): TIAGO MENDONÇA E OUTRO (A/S) RECD. (A/S): MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
ADV. (A/S): CARLOS SIMAS ROCHA INTDO. (A/S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF ADV. (A/S): RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que se debate o Tema 796 da repercussão geral, assim descrito:

"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado."

Na origem, Lusframa Participações Societárias Ltda. impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Secretário da Fazenda Municipal de São João Batista/SC, que reconheceu apenas parcialmente a imunidade do ITBI sobre os bens imóveis incorporados ao patrimônio da impetrante a título de realização de capital, exigindo o tributo sobre a diferença entre o valor do capital social e o dos bens transferidos.

Informou que (a) foi constituída em maio de 2010, com objeto social determinado para participação societária e acionária em outras empresas, e representação comercial por conta própria ou de terceiros; (b) o capital social da empresa é R\$ 24.000,00, e foi integralizado mediante bens imóveis (17 imóveis) cujo valor total (R\$ 802.724,00) é superior ao do capital social; e (c) a autoridade coatora se nega a emitir guia de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com imunidade integral na transferência dos bens, conforme previsão do art. 156 da Constituição Federal de 1988 e art. 36 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a imunidade atinge somente o montante do capital social da empresa a ser integralizado.

Ao final, pleiteou a declaração de imunidade tributária em relação ao ITBI sobre o valor total do imóvel transferido.



A sentença concedeu a segurança, para reconhecer a imunidade tributária sobre todos os imóveis transmitidos e determinar que a autoridade coatora se abstinhasse de exigir o ITBI sobre a transmissão daqueles bens incorporados ao patrimônio da impetrante a título de realização de capital.

Em seguida, o Tribunal de origem, em sede de apelação e de reexame necessário, reformou a sentença, para denegar a segurança, ao entendimento de que a imunidade do ITBI incide apenas sobre o valor do imóvel suficiente para a integralização do capital social da empresa.

Decidiu que deve ser tributada a diferença, no montante de R\$ 778.724,00, apurada entre os valores do capital social subscrito e dos bens dados em pagamento para a integralização das quotas sociais. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO — ITBI — INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA — IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, INCISO II, DA CF/1988) — VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS RESPECTIVOS — IMUNIDADE QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL E DAS COTAS (INTEGRALIZADAS COM IMÓVEIS — EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO — SENTENÇA REFORMADA. A imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso II do § 2º do art. 156, da Constituição Federal de 1988 impede a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis "inter vivos" somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Vale dizer, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá incidência do tributo. Opostos Embargos de Declaração pela impetrante, foram rejeitados.

Irresignada, a empresa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, em que aponta violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, além dos princípios constitucionais da legalidade (37, II), da reserva legal (art. 5º, II), da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI), da livre iniciativa e da autonomia da vontade (arts. 1º, IV, e 170). Para tanto, sustenta que:

a) o fisco municipal e o acórdão recorrido afrontaram o princípio da legalidade ao impor limitação à imunidade do ITBI em relação aos imóveis destinados à integralização do capital social da empresa, haja vista tal restrição não estar prevista na Constituição, nem no Código Tributário Nacional;

b) "ocorrendo a incorporação dos imóveis para fins de integralização do capital social, deve a empresa ora recorrente estar imune ao pagamento do tributo de transmissão sobre bens imóveis, não podendo ser criado ou estabelecido nenhum outro critério além daqueles previstos na Constituição Federal, a aplicação de tal critério de exceção traduz verdadeira insegurança jurídica ao empresariado;

c) "negar a concessão de benefício constitucional para empresa recorrente seria negar consequentemente o preceito que visa motivar os particulares à exploração de atividades empresariais", o que contraria o objetivo da norma inscrita no art. 170 da CF;

d) a vedação ao poder de tributar constante no art. 156, § 2º, I, constitui imunidade tributária e, como tal, não admite limitação; e

e) as ilações do Tribunal de origem a respeito das razões pelas quais se pretende destinar imóveis em valor superior ao da integralização do capital viola a livre iniciativa, pois não há nenhuma norma legal que proíba tal conduta, uma vez que o valor dos imóveis excedente ao capital social figurará na contabilidade empresarial com reserva capital, conforme o acordo de vontade dos sócios consubstanciado no contrato social da empresa.

Sem contrarrazões.



O Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem. Em 5/3/2015, o Plenário desta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria.

Em parecer, a Procuradoria-Geral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. TELEOLOGIA DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE PREVINE A TRIBUTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1 – A interpretação teleológica do preceito conduz ao entendimento de que a imunidade do art. 156, § 2º, I, da Constituição, na transmissão dos bens necessários para a formação do capital social de sociedade limitada, não se estende para além do valor estipulado no contrato social a esse título.

2 – Parecer pelo desprovimento do recurso.

A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF foi admitida no processo como terceira interessada.

É o essencial a ser relatado.

Na questão com repercussão geral reconhecida, debate-se o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor desses bens excede o limite do capital social a ser integralizado.

A Constituição Federal confere imunidade em relação ao ITBI da seguinte forma:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

A CARTA MAGNA de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis. Do teor do inciso I acima, extrai-se que não incide o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica.

O inciso I do art. 36 do Código Tributário Nacional reflete esse mandamento constitucional, ao dispor que:

"Art. 36 Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I – quando efetuada sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito”;

II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.



Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. "

Esse dispositivo foi recepcionado pela CF/88, por se harmonizar com o teor do inciso I do § 2º, do art. 156 da Lei Maior.

Segundo KIYOSHI HARADA, o que a norma imuniza não é qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica; a norma imunizante diz respeito exclusivamente ao pagamento em bens ou direitos que o sócio faz para integralização do capital social subscrito que pode ocorrer tanto no início da constituição de pessoa jurídica, como também posteriormente por ocasião do aumento do capital (ITBI - Doutrina e prática. São Paulo: Atlas. 2010, p. 85).

Comparando-se a redação do aludido inciso I com a do art. 9º, § 2º da Emenda Constitucional 18/1965, verifica-se que não há, nesse parágrafo 2º da EC, a menção à situação de "transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica". Vejamos:

"Art. 9º Compete aos Estados o imposto sobre a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por natureza ou por cessão física, como definidos em lei, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia.

(...)

§ 2º O imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos neste artigo, para sua incorporação ao capital de pessoas jurídicas, salvo o daquelas cujas atividades preponderantes, como definida em lei complementar, seja a venda ou a locação da propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. "

Como se vê, a ressalva contida no § 2º acima transcrito referia-se à circunstância diferente daquelas eleitas pelo inciso I do § 2º do art. 156 da atual Constituição Federal. Para maior clareza, comparemos:

Art. 156 - (...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Essa distinção é importante, porque tem levado certa parte da doutrina e da jurisprudência a defender a não incidência do ITBI sobre o valor dos bens incorporados que for excedente ao do capital subscrito. Argumentam os defensores desta posição que qualquer incorporação de bens à pessoa jurídica é imune, pois as únicas exceções são aquelas expressamente definidas no final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88. Com essa alegação, propugnam que o intérprete não pode inovar criando outras hipóteses excepcionais.

A esse respeito, o já mencionado professor HARADA esclarece que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.

Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da "incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são



absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações" (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A.); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.).

Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital.

Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - "nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil" - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão "nesses casos" não alcança o "outro caso" referido na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

Esse entendimento é corroborado pela didática lição de EDUARDO DE MORAES SABBAG que, ao comentar o dispositivo constitucional em questão, apresenta um exemplo bastante esclarecedor:

"ITBI e Imunidades

Art. 156. "Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º O imposto previsto no inciso II

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem. (Grifos no original)

O ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda desses bens. A preponderância existe se a atividade representar mais de 50% da receita operacional, nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes (art. 37, § 1º, do CTN).

Exemplificando: Se uma empresa "A" (atividade: fabricação de azulejos), com sede em Brasília, incorpora uma empresa "B" (atividade: compra e venda de imóveis, preponderantemente), com sede no Rio de Janeiro, havendo transmissão de todos os direitos e bens da empresa "B" para a adquirente "A", incluindo um imóvel localizado na cidade do Recife, pergunta-se: pagar-se-á ITBI a quem?

Não se pagará o ITBI, uma vez que o caso de imunidade específica. Se a empresa "A" fosse aquela que tivesse comprado e vendido imóveis, teríamos, sim, a incidência do ITBI (para Recife, no caso). Note que a empresa adquirente é quem exerce a preponderante, havendo, portanto, nítida regra imunitória. (Elementos do Direito, Direito Tributário, 8ª ed. São Paulo: Premier Máxima, 2007, p. 340), (grifos no original).



Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito.

Revelaria interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo - como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital.

Essa extensão interpretativa em termos de imunidades não é aceita por nossa SUPREMA CORTE, por constituir exceção constitucional à capacidade tributária: IMUNIDADE – CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. A imunidade encerra exceção constitucional à capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os preceitos regedores de forma estrita.

IMUNIDADE – EXPORTAÇÃO – RECEITA – LUCRO. A imunidade prevista no inciso I do § 2º do artigo 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras. LUCRO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EMPRESAS EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas exportadoras a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. (RE 564413, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe de 6/12/2010) EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À CPMF INCIDENTE SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal é claro ao limitar a imunidade apenas às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação. II - Em se tratando de imunidade tributária a interpretação há de ser restritiva, atentando sempre para o escopo pretendido pelo legislador. III - A CPMF não foi contemplada pela referida imunidade, porquanto a sua hipótese de incidência - movimentações financeiras - não se confunde com as receitas. IV - Recurso extraordinário desprovido. (RE 566.259, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe de 24/9/2010)

Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.

Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores.

O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o



desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R\$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R\$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.

Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado. Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, com a fixação da seguinte Tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.” (Grifo nosso)

Resta claro pelo voto do Ministro Alexandre de Moraes, que inclusive subsidiou a Decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 796.376 que, **sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.**

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que seja recebida a presente Informação e seja **julgado improcedente o pedido apresentado no presente Mandado de Segurança, denegando assim a segurança in totum**, haja vista que a autoridade coatora somente cumpriu os preceitos do Art.156, II da Constituição Federal.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento

Guarapari (ES), 16 de agosto de 2021.


GABRIEL COSTA ARAÚJO
Secretário Municipal da Fazenda



05/08/2020

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.376 SANTA CATARINA

RELATOR	: MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S)	: LUSFRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADV.(A/S)	: TIAGO MENDONÇA E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S)	: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
ADV.(A/S)	: CARLOS SIMAS ROCHA
INTDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF
ADV.(A/S)	: RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

ACÓRDÃO



Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 25

RE 796376 / SC

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por maioria, apreciando o Tema 796 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator), EDSON FACHIN, RICARDO LEWANDOWSKI e CÁRMEN LÚCIA. Foi formulada a seguinte tese de Repercussão Geral: "A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Falaram: pela recorrente, a Dra. Graziela Biason Guimarães; e, pela interessada, o Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da Silva

Brasília, 05 de agosto de 2020.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Redator p/ o Acórdão



05/08/2020

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.376 SANTA CATARINA

RELATOR	: MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S)	: LUSFRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADV.(A/S)	: TIAGO MENDONÇA E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S)	: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
ADV.(A/S)	: CARLOS SIMAS ROCHA
INTDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF
ADV.(A/S)	: RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, como relatório, as informações prestadas pelo assessor Dr. Antônio Claret de Souza Júnior:

Lusframa Participações Societárias Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, dando provimento a apelação do Município de São João Batista e a remessa necessária, assentou a incidência do Imposto sobre Transmissão entre Vivos de Bens Imóveis – ITBI na integralização do capital da empresa, afastando a imunidade tributária versada no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Segundo o Colegiado de origem, o benefício alcança apenas a parcela do valor do imóvel suficiente à satisfação da subscrição. Assentou que a intenção do constituinte foi facilitar a criação de novas sociedades e a movimentação de bens de raiz. Ressaltou haver, no artigo 36 do Código Tributário



RE 796376 / SC

Nacional, menção a não incidência limitada ao capital a ser integralizado, descabendo conceder imunidade quanto ao valor total da propriedade incorporada. Assentou não atuar a empresa no comércio imobiliário, inexistindo razão para a incorporação de bens avaliados em quantia superior às cotas.

O acórdão impugnado foi sintetizado na seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO - ITBI - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, INCISO II, DA CF/1988) - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS RESPECTIVOS - IMUNIDADE QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL E DAS COTAS INTEGRALIZADAS COM IMÓVEIS - EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

A imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso II do § 2º do art. 156, da Constituição Federal de 1988 impede a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis "inter vivos" somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Vale dizer, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá incidência do tributo.

A recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXXVI; 37, cabeça; 156, § 2º, inciso II; e 170 da Constituição Federal. Sustenta ausente disciplina voltada a restringir, para fins de gozo da imunidade, considerada a forma de realização do capital. Esclarece ter outro Município do mesmo Estado reconhecido, sem ressalva, o benefício. Realça que a não incidência visa facilitar a entrada de pessoas naturais e jurídicas no mercado. Salienta haver atendido, para usufruir a



RE 796376 / SC

imunidade, os requisitos estabelecidos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Diz da impossibilidade de presumir-se não ser intenção da empresa integralizar o capital. Enfatiza constituir o contrato social relação entre particulares, predominando a autonomia da vontade. Anota que, de acordo com o ato constitutivo, a diferença entre o preço dos imóveis e a quantia integralizada é contabilizada como reserva de capital.

O recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões – certidão de 25 de outubro de 2012.

O extraordinário foi admitido na origem.

Em 5 de março de 2015, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema. Eis a ementa do acórdão, publicado no dia 20 subsequente:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal.

A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.



RE 796376 / SC

**TELEOLOGIA DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE
PREVINE A TRIBUTAÇÃO. DESPROVIMENTO.**

1 – A interpretação teleológica do preceito conduz ao entendimento de que a imunidade do art. 156, § 2º, I, da Constituição, na transmissão dos bens necessários para a formação do capital social de sociedade limitada, não se estende para além do valor estipulado no contrato social a esse título.

2 – Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.



05/08/2020

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.376 SANTA CATARINA

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR):

ITBI – IMUNIDADE. Revela-se imune ao Imposto sobre a Transmissão entre Vivos de Bens Imóveis – ITBI a incorporação destes ao patrimônio de pessoa jurídica, ainda que o valor total dos bens exceda o limite do capital social a ser integralizado – inteligência do artigo 156, § 20, inciso I, da Constituição Federal.

Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça recursal, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.

O capital social da recorrente foi integralizado mediante incorporação de imóveis com valor superior ao das cotas subscritas, sendo a diferença lançada, à conta de ágio, no patrimônio líquido.

Para satisfazer as necessidades públicas, os Estados recorrem a meios universais: recebem doações, auferem renda explorando patrimônio próprio, exigem tributos, impõem penalidades, tomam empréstimos e imprimem moeda¹. A tributação sobressai dentre as fontes de receita, trazendo consigo a desvantagem de tornar menos atrativa a atividade sobre a qual recai. Daí por que o constituinte, em determinadas situações, limitou o poder de tributar. Justifica-se a interpretação teleológica das regras de imunidade: a verdadeira razão da lei está na finalidade para a qual editada e no exame dos fatos que para ela contribuíram.

Assim tem entendido o Supremo, quando em análise casos situados na zona limítrofe entre tributação e imunidade. No julgamento do recurso extraordinário nº 595.676/RJ, de minha relatoria, acórdão publicado no

1 BALEEIRO, Aliomar. *Uma introdução à Ciência das Finanças*. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 151.



RE 796376 / SC

Diário da Justiça de 18 de dezembro de 2017, o Pleno, reconhecendo amplitude máxima ao artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal, assentou alcançar a imunidade cultural componentes eletrônicos de unidade didática com fascículos periódicos impressos. Idêntica postura adotou ao apreciar o extraordinário de nº 330.817/RJ, relator o ministro Dias Toffoli, acórdão veiculado no Diário da Justiça do dia 26 de fevereiro de 2018, ocasião em que proclamou imunes os livros eletrônicos e os aparelhos destinados exclusivamente à leitura. E não foi outra a óptica no recurso extraordinário nº 325.822/SP, redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça de 14 de maio de 2004, oportunidade na qual reconheceu a extensão, ao patrimônio, à renda e aos serviços dos cultos religiosos, da imunidade relativa aos templos.

Lógica semelhante deve ser adotada no caso concreto. Dispõe o artigo 156, § 2º, inciso I, da Lei Maior:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

[...]

A regra não é novidade do regime constitucional instaurado em 1988. Havia, na Emenda nº 18/1965, dispositivo equivalente – “O impôsto



RE 796376 / SC

não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos neste artigo, para sua incorporação ao capital de pessoas jurídicas [...]” –, replicado sem maior alteração semântica no texto de 1967 e na Emenda nº 1/1969. Antes, as Constituições de 1934, 1937 e 1946 previam expressamente a incidência do tributo nas incorporações ao capital das sociedades.

Na exposição de motivos da Emenda nº 18/1965, o professor Otávio Bulhões, à época ministro da Fazenda, demonstrou preocupação com a ausência de substrato econômico a legitimar a incidência do ITBI:

Os impostos relacionados com a transmissão de propriedade *inter vivos*, hoje admitidos pela Constituição, são destituídos de fundamento econômico e por esse motivo a Comissão sugere que sejam retificados.

O fato de alguém vender uma propriedade a outrem não autoriza admitir, pela simples transmissão, o exercício de uma atividade econômica suscetível de tributação. Se o vendedor lucra com a transação, se auferir um ganho de capital porque comprou por um preço e vendeu por outro, obtendo um lucro real, esse lucro deve ser taxado, não, porém, sobre o valor da transação. O vendedor está sujeito a um imposto próprio – o imposto sobre ganhos de capital, seja o bem móvel ou imóvel.

A meu ver, deveríamos suprimir integralmente do sistema tributário os impostos de transmissão de propriedade *inter vivos*. São impostos sem sentido econômico. Criam empecilhos de toda ordem e representam sério obstáculo ao desenvolvimento econômico do País.

As ressalvas seriam duas: imunidade na incorporação ao capital de sociedades e dedução, do ITBI, do valor devido a título de Imposto sobre a Renda, benefício esse não mantido na Carta de 1988.

A razão de ser da imunidade – e nada surge sem causa, princípio lógico e racional do determinismo – é facilitar o trânsito jurídico de bens, considerado o ganho social decorrente do desenvolvimento nacional, objetivo fundamental da República – artigo 3º, inciso III, da Lei Maior.



RE 796376 / SC

Embora, ordinariamente, a contrapartida dos sócios se exprima na figura do capital social, nem sempre isso ocorre, seja em razão da vontade, seja em consequência de fatores econômicos. Nesses casos, o ágio alimentará outra conta do patrimônio líquido, chamada reserva de capital. Eis o que prescreve o artigo 182, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.404/1976²:

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;

[...]

O ágio na subscrição de cotas ou ações representa investimento direto em sociedade empresária, tanto quanto a integralização de capital pura e simples, devendo receber idêntico tratamento. É consagrada a noção: onde houver o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito.

E nem se diga ter o constituinte, ao lançar a expressão “em realização de capital”, afastado a interpretação teleológica ora proposta. Mediante a previsão, buscou-se manter a incidência do ITBI em outras formas de aquisição da propriedade, como a dação em pagamento e a compra e venda – situações nas quais os bens se incorporam ao patrimônio da pessoa jurídica, ausente realização de capital.

Conheço do recurso extraordinário e o provejo, para, reformando o acórdão recorrido, deferir a ordem, afastando a incidência do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio da recorrente. Eis a tese: “Revela-se imune, sob o ângulo tributário, a incorporação de imóvel ao patrimônio

2 O dispositivo é aplicável às sociedades limitadas por força do artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil – “O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima”.



RE 796376 / SC

de pessoa jurídica, ainda que o valor total exceda o limite do capital social a ser integralizado”.

É como voto.



05/08/2020

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.376 SANTA CATARINA

RELATOR	: MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S)	: LUSFRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADV.(A/S)	: TIAGO MENDONÇA E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S)	: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
ADV.(A/S)	: CARLOS SIMAS ROCHA
INTDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF
ADV.(A/S)	: RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que se debate o Tema 796 da repercussão geral, assim descrito:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.”

Na origem, Lusframa Participações Societárias Ltda. impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Secretário da Fazenda Municipal de São João Batista/SC, que reconheceu apenas parcialmente a imunidade do ITBI sobre os bens imóveis incorporados ao patrimônio da impetrante a título de realização de capital, exigindo o tributo sobre a diferença entre o valor do capital social e o dos bens transferidos.



RE 796376 / SC

Informou que (a) foi constituída em maio de 2010, com objeto social determinado para participação societária e acionária em outras empresas, e representação comercial por conta própria ou de terceiros; (b) o capital social da empresa é R\$ 24.000,00, e foi integralizado mediante bens imóveis (17 imóveis) cujo valor total (R\$ 802.724,00) é superior ao do capital social; e (c) a autoridade coatora se nega a emitir guia de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com imunidade integral na transferência dos bens, conforme previsão do art. 156 da Constituição Federal de 1988 e art. 36 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a imunidade atinge somente o montante do capital social da empresa a ser integralizado.

Ao final, pleiteou a declaração de imunidade tributária em relação ao ITBI sobre o valor total do imóveis transferidos.

A sentença concedeu a segurança, para reconhecer a imunidade tributária sobre todos os imóveis transmitidos e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ITBI sobre a transmissão daqueles bens incorporados ao patrimônio da impetrante a título de realização de capital.

Em seguida, o Tribunal de origem, em sede de apelação e de reexame necessário, reformou a sentença, para denegar a segurança, ao entendimento de que a imunidade do ITBI incide apenas sobre o valor do imóvel suficiente para a integralização do capital social da empresa.

Decidiu que deve ser tributada a diferença, no montante de R\$ 778.724,00, apurada entre os valores do capital social subscrito e dos bens dados em pagamento para a integralização da quotas sociais. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO — ITBI — INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS
PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA
JURÍDICA — IMUNIDADE TRIBUTARIA (ART. 156, § 2º,

2



RE 796376 / SC

INCISO II, DA CF/1988) – VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS RESPECTIVOS – IMUNIDADE QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL E DAS COTAS (INTEGRALIZADAS COM IMÓVEIS – EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. A imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso II do § 2º do art. 156, da Constituição Federal de 1988 impede a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis "inter vivos" somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Vale dizer, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá incidência do tributo.

Opostos Embargos de Declaração pela impetrante, foram rejeitados.

Irresignada, a empresa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, em que aponta violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, além dos princípios constitucionais da legalidade (37, II), da reserva legal (art. 5º, II), da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI), da livre iniciativa e da autonomia da vontade (arts. 1º, IV, e 170). Para tanto, sustenta que:

a) o fisco municipal e o acórdão recorrido afrontaram o princípio da legalidade ao impor limitação à imunidade do ITBI em relação aos imóveis destinados à integralização do capital social da empresa, haja vista tal restrição não estar prevista na Constituição, nem no Código Tributário Nacional;

b) *"ocorrendo a incorporação dos imóveis para fins de integralização do capital social, deve a empresa ora recorrente estar imune ao pagamento do tributo de transmissão sobre bens imóveis, não podendo ser criado ou estabelecido nenhum outro critério além daqueles previstos na Constituição Federal, a aplicação de tal critério de exceção traduz verdadeira insegurança jurídica ao empresariado;*



RE 796376 / SC

c) “negar a concessão de benefício constitucional para empresa recorrente seria negar consequentemente o preceito que visa motivar os particulares à exploração de atividades empresariais”, o que contraria o objetivo da norma inscrita no art. 170 da CF;

d) a vedação ao poder de tributar constante no art. 156, § 2º, I, constitui imunidade tributária e, como tal, não admite limitação; e

e) as ilações do Tribunal de origem a respeito das razões pelas quais se pretende destinar imóveis em valor superior ao da integralização do capital viola à livre iniciativa, pois não há nenhuma norma legal que proíba tal conduta, uma vez que o valor dos imóveis excedente ao capital social figurará na contabilidade empresarial com reserva capital, conforme o acordo de vontade dos sócios consubstanciado no contrato social da empresa.

Sem contrarrazões.

O Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem.

Em 5/3/2015, o Plenário desta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria.

Em parecer, a Procuradoria-Geral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. TELEOLOGIA DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE PREVINE A TRIBUTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1 – A interpretação teleológica do preceito conduz ao entendimento de que a imunidade do art. 156, § 2º, I, da



RE 796376 / SC

Constituição, na transmissão dos bens necessários para a formação do capital social de sociedade limitada, não se estende para além do valor estipulado no contrato social a esse título.

2 – Parecer pelo desprovimento do recurso.

A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF foi admitida no processo como terceira interessada.

É o essencial a ser relatado.

Na questão com repercussão geral reconhecida, debate-se o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor desses bens excede o limite do capital social a ser integralizado.

A Constituição Federal confere imunidade em relação ao ITBI da seguinte forma:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica **em realização de capital, nem** sobre a transmissão de bens ou direitos



RE 796376 / SC

decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, **salvo se, nesses casos**, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

A CARTA MAGNA de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis. Do teor do inciso I acima, extrai-se que não incide o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica.

O inciso I do art. 36 do Código Tributário Nacional reflete esse mandamento constitucional, ao dispor que:

“Art. 36 Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I – quando efetuada sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica **em pagamento de capital nela subscrito**”;

II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.”

Esse dispositivo foi recepcionado pela CF/88, por se harmonizar com o teor do inciso I do § 2º, do art. 156 da Lei Maior.

Segundo KIYOSHI HARADA, o que a norma imuniza não é qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica; a norma imunizante diz respeito exclusivamente ao pagamento



RE 796376 / SC

em bens ou direitos que o sócio faz para integralização do capital social subscrito que pode ocorrer tanto no início da constituição de pessoa jurídica, como também posteriormente por ocasião do aumento do capital (ITBI - Doutrina e prática. São Paulo: Atlas. 2010, p. 85).

Comparando-se a redação do aludido inciso I com a do art. 9º, § 2º da Emenda Constitucional 18/1965, verifica-se que não há, nesse parágrafo 2º da EC, a menção à situação de “transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica”. Vejamos :

“Art. 9º Compete aos Estados o imposto sôbre a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por natureza ou por cessão física, como definidos em lei, e de direitos reais sôbre imóveis, exceto os direitos reais de garantia.

(...)

§ 2º O imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos neste artigo, para sua incorporação ao capital de pessoas jurídicas, **salvo** o daquelas cuja atividade preponderante, como definida em lei complementar, seja a venda ou a locação da propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.”

Como se vê, a ressalva contida no § 2º acima transcrito referia-se à circunstância diferente daquelas eleitas pelo inciso I do § 2º do art. 156 da atual Constituição Federal. Para maior clareza, comparemos:

Art. 156 - (...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos **incorporados** ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de



RE 796376 / SC

capital, **nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos,** a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Essa distinção é importante, porque tem levado certa parte da doutrina e da jurisprudência a defender a não incidência do ITBI sobre o valor dos bens incorporados que for excedente ao do capital subscrito. Argumentam os defensores desta posição que qualquer incorporação de bens à pessoa jurídica é imune, pois as únicas exceções são aquelas expressamente definidas no final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88. Com essa alegação, propugnam que o intérprete não pode inovar criando outras hipóteses excepcionais.

A esse respeito, o já mencionado professor HARADA esclarece que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens *decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica*.

É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.

Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações



RE 796376 / SC

(art. 228 da Lei das S.A.).

Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital.

Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “ *nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil* ” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

Esse entendimento é corroborado pela didática lição de EDUARDO DE MORAES SABBAG que, ao comentar o dispositivo constitucional em questão, apresenta um exemplo bastante esclarecedor:

“ITBI e Imunidades

Art. 156. “*Compete aos Municípios instituir impostos sobre:*
(...)

II - *transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;*

§ 2º *O imposto previsto no inciso II:*



RE 796376 / SC

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem. (grifos no original)

O ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante da *adquirente* for a compra e venda desses bens. A preponderância existe se a atividade representar mais de 50% da receita operacional, nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes (art. 37, § 1º, do CTN).

Exemplificando: Se uma empresa “A” (atividade: *fabricação de azulejos*), com sede em Brasília, *incorpora* uma empresa “B” (atividade: *compra e venda de imóveis*, preponderantemente), com sede no Rio de Janeiro, havendo transmissão de todos os direitos e bens da empresa “B” para a adquirente “A”, incluindo um imóvel localizado na cidade do Recife, pergunta-se: pagar-se-á ITBI a quem?

Não se pagará o ITBI, uma vez que o caso de imunidade específica. Se a empresa “A” fosse aquela que tivesse comprado e vendido imóveis, teríamos, sim, a incidência do ITBI (para Recife, no caso). Note que a empresa adquirente é quem exerce a preponderante, havendo, portanto, nítida regra imunitória. (Elementos do Direito, Direito Tributário, 8ª ed. São Paulo: Premier Máxima, 2007, p. 340), (grifos no original).

Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte



RE 796376 / SC

desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito.

Revelaria interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo - como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital.

Essa extensão interpretativa em termos de imunidades não é aceita por nossa SUPREMA CORTE, por constituir exceção constitucional à capacidade tributária:

IMUNIDADE – CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. A imunidade encerra exceção constitucional à capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os preceitos regedores de forma estrita. IMUNIDADE – EXPORTAÇÃO – RECEITA – LUCRO. A imunidade prevista no inciso I do § 2º do artigo 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras. LUCRO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EMPRESAS EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas exportadoras a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.(RE 564413, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe de



RE 796376 / SC

6/12/2010)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À CPMF INCIDENTE SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal é claro ao limitar a imunidade apenas às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação. II - Em se tratando de imunidade tributária a interpretação há de ser restritiva, atentando sempre para o escopo pretendido pelo legislador. III - A CPMF não foi contemplada pela referida imunidade, porquanto a sua hipótese de incidência - movimentações financeiras - não se confunde com as receitas. IV - Recurso extraordinário desprovido. (RE 566.259, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe de 24/9/2010)

Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.

Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores.

O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de



RE 796376 / SC

capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R\$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R\$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.

Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, com a fixação da seguinte Tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”



Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 25 de 25

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.376

PROCED. : SANTA CATARINA

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RECTE.(S) : LUSFRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

ADV.(A/S) : TIAGO MENDONÇA (31119/SC) E OUTRO(A/S)

RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA

ADV.(A/S) : CARLOS SIMAS ROCHA (18895B/SC)

INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS
DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF

ADV.(A/S) : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA (81438/RJ)

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 796 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Falaram: pela recorrente, a Dra. Graziela Biason Guimarães; e, pela interessada, o Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020.

Composição: Ministros Dias Toffoli (Presidente), Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

